Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul

Rua Ernesto Alves, 945 - Bairro: Centro - CEP: 96810144 - Fone: (51) 3098-5791 - Email: frsantcruz2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012554-07.2021.8.21.0026/RS

AUTOR: PEDRO LUCAS COLOME

RÉU: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação condenatória c/c tutela de urgência", intentada por **PEDRO LUCAS COLOMÉ** contra o **UNIMED – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA,** mediante o qual pretende o requerente compelir a requerida ao fornecimento de medicação. Refere ser beneficiário do plano de assistência à saúde oferecido pela demandada. Segundo a inicial, e de acordo com os atestados médicos, o demandante é portador de "Dermatite Atópica Grave (CID L20) associada a Doença de Crohn (CID K50)". Assim, foi prescrito o uso do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 300mg a cada 14 dias. Ao solicitar o fármaco junto a parte ré, não obteve êxito. Postula, em sede de tutela de urgência, a determinação judicial para que a demanda forneça/custeie o medicamento pleiteado, sob pena de multa. Ao final, requer seja definitiva a concessão da liminar. Pugna pela concessão da AJG e pela inversão do ônus da prova.

Concedido o benefício da justiça gratuita, invertido o encargo probatório e deferida a tutela de urgência (E3).

A requerida opôs embargos de declaração (E14), que não foram recebidos (E16).

Em contestação (E23), a demandada argui a inaplicabilidade do CDC, bem como da inversão do ônus da prova. Tece comentários sobre o regulamento do plano de saúde ao sócio cooperado, o qual o autor é beneficiário, alegando que não há previsão de cobertura para o fármaco pleiteado. Alega que o genitor do demandante (médico cooperado UNIMED) poderia apresentar recurso aos órgãos internos societários quanto à negativa de cobertura para análise. Postula pela improcedência da ação.

Réplica (E28).

Na decisão do E29 foram fixados os pontos controvertidos, ratificada a inversão do encargo probatório e oportunizada a dilação probatória.

As partes pugnaram por prova testemunhal (E33 e 34).

A demandada interpôs agravo postulando a inaplicabilidade do CDC e ada inversão do ônus da prova (E39).

No certame de instrução foram inquiridos Ronaldo Ferraz Bento Pereira e Vinicius Torres Richter e Leonardo Atílio Chitolina na condição de informantes, E58.

Comunicado o provimento do recurso (E63)

Sobreveio manifestação das partes (E62 e 64)

Intimadas, as partes apresentaram razões finais (E72 e 73).

Vieram os autos conclusos para sentença.

Relatei. Passo a fundamentar.

O Juízo é competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia. As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são legítimas. Não há nulidades arguidas e, tampouco, identificadas e, sequer, exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

Inicialmente, registro que o julgamento do recurso de agravo de instrumento afastou aplicação das normas consumeristas e, assim, da inversão do ônus da prova, tornando imutável a questão no ponto.

Quanto ao pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova veiculado pelo autor entendo estar preclusa, porquanto requerida quando já exaurida a fase processual para produção de provas e declarada seu encerramento. Seu reconhecimento, neste momento processual, não só seria inviável como implicaria em nulidade da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à análise do mérito.

Resta incontroversa a condição do demandante de beneficiário dependente de médico (seu genitor) cooperado da demandada UNIMED VTRP, a doença que acomete o requerente, bem como a previsão de cobertura para a enfermidade em comento.

A discussão centra-se, fundamentalmente, na existência ou não de cobertura e na obrigatoriedade de fornecimento/custeio da medicação prescrito ao autor.

Muito embora a condição do autor seja de dependente de médico cooperado, o regulamento de prestação de assistência à saúde ao sócio cooperado aportado aos autos com a contestação não exclui de cobertura o tratamento de "dermatite atópica grave (CID L20) associada a doença de Crohn (CID K50)", que está acometido o autor.

A Demandada, entretanto, se opõe ao pleito deduzido na exordial sob o argumento de que o medicamento indicado não está contemplado no no Rol de Procedimentos Unimed – DC0266, documento elaborado pela Cooperativa demandada, que dispõe sobre a cobertura devida ao médico cooperado e seus familiares.

Ainda, que o art. 14, III, do Regulamento de Assistência à Saúde dispõe que haverá cobertura sobre medicamentos registrados ANVISA, quando do atendimento ambulatorial dos procedimentos e eventos previstos no "Rol de Procedimentos Unimed – DC0266" . Acresce que o medicamento não está previso no Rol da ANS.

Primeiro, muito embora inaplicável as regras de direito do consumidor, incide sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes a disciplina contida na norma civilista devendo a relação jurídica ser analisada sob o princípio da boa e a interpretação no sentido que for mais benéfico a parte que não redigiu as regras:

"Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração".

É indubitável que na condição de dependente, aderiu o autor à normas preestabelecidas unilateralmente pela demandada, como um típico contrato de adesão.

A aquiescência à assistência de saúde fornecida pela cooperativa, assim como demais planos de saúde, seja neste caso com vínculo estabelecido por meio de sócio cooperado e noutro como consumidor adquirente do plano com pagamento integral da mensalidade, tem como precípua finalidade a prestação de serviço atendimento à saúde, de forma que as exclusões, devem constar, obrigatoriamente, de forma expressa.

A prova material e oral é robusta em demonstrar que o medicamento pleiteado pelo autor, aprovado no Brasil há mais de 1 ano, possui eficácia comprovada em diversos pacientes e, relativamente ao autor, foi efetiva e eficaz em poucos dias de início do tratamento, segundo o médico dermatologista Vinicius Torres Richter, que assiste ao autor conjuntamente com o medico Ronaldo Ferraz Bento Teixeira, também, dermatologista.

Vinicius T. Richter, refere que assiste o demandante há 3 anos, e que prescreveu o tratamento com DUPIXENT para dermatite atópica associada à doença de Crohn, pois os tratamentos convencionais anteriores, que seguiram protocolos médicos, não obtiveram resultado. Acredita que não consta no rol da ANS por que há lentidão, estando a medicação aprovada há 4 anos nos EUA e aprovado no Brasil há 1 ano e 8 meses, mesmo período que o autor faz uso. Salienta não haver medicamento similar no Brasil que produza resultados. Aduz que a não utilização do fármaco agravaria o quadro, causando incapacitação física e emocional. Afirma que para o autor é a última solução.

Ronaldo Ferraz Bento Ferreira, disse que o quadro atual do autor é significativamete melhor em razão do tratamento com DUPIXENT, com controle das patologias. Diz que o autor não responde a terapias convencionais e que a nova medicação tem controle quase total. Declara que profissionais e estudos científicos revelaram que a eficácia do fármaco vai além do esperado. O autor está com a doença de Chron controlada com DUPIXENT, não havendo medicamento que o substitua e que a suspensão do tratamento causará uma piora significativa e imediata, atingindo áreas vitais como mãos, pés, rosto, o que afeta a vida do demandante como um todo. Trata patologia idêntica a do autor há mais de 40 anos e garante que nada há tratamento melhor do que o ora realizado.

O depoimento de Leonardo Chitollina, analista administrativo da demandada, informou sobre a condição do autor de dependente de cooperado e a tramitação de recurso de revisão de negativa.

De atentar que muito embora, segundo a demandada, não se verifique a incorporação do medicamento pleiteado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, por outro, não há informação de que houve tentativa de encaminhamento de solicitação para inclusão, eventual apreciação do pedido a crivo da COSAÚDE[1] e recusa.

Não havendo proposição de inclusão não se pode dizer que está afastada a evidência de eficácia do fármaco, mas tão somente que não fora encaminhado à inclusão no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde, por via de consequência no Rol de medicamentos da ANS e na DUT.

Ademais, identifico que não há qualquer comprovação de que a medicação pleiteada não se encontra registrada/regularizada no país, tampouco que tenha sido classificada como de caráter experimental pelo Conselho Federal de Medicina. As evidências dos autos, pelo contrário, indicam medicação aprovada pela ANVISA, bem como que a prescrição está em conformidade com a bula, consoante publicação no DOU (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dupixent-dupilumabe-nova-indicacao).

Segundo registro na página da ANVISA no site do Ministério da Saúde:

"O dupilumabe demonstrou benefícios clinicamente significativos, combinados com um perfil de segurança favorável, sem a toxicidade e os efeitos colaterais comumente observados com os imunossupressores sistêmicos não seletivos. Foi a primeira terapia biológica aprovada para pacientes adultos e adolescentes com DA e agora também foi demonstrado um perfil de benefício-risco positivo no tratamento da dermatite atópica em crianças =6 anos de idade".

Nesse sentido, entendo que a recusa da demandada em fornecer o fármaco necessário para o tratamento de que o autor necessita não se afigura legítimo. Ora, pelo exame da inicial, seus documentos e prova oral, inclusive pela ausência de sugestão a tratamento diverso pela auditoria médica da Unimed que avaliou o pedido na via administrativa, o que embora indevido, comumente acontece, verifico a veracidade da patologia apresentada pelo autor, beneficiário do plano de saúde, a eficácia do tratamento, o qual deve arcar com o tratamento indicado pelo médico assistente.

Veja-se posicionamento junto ao Tribunal de Justiça, em análises de casos que envolvem a mesma medicação aqui pleiteada:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO. MEDICAMENTO* ***LYNPARZA (OLARIBE). COBERTURA DEVIDA.*** ***1. A obrigação da ré é de fornecimento de todos os fármacos necessários ao tratamento, na forma e dosagem recomendada pelo médico assistente. 2. Reconhecido que o contrato entabulado entre as partes prevê a cobertura de tratamento da patologia apresentada pela parte autora, revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura os medicamentos correlatos. O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado.*** *Precedentes desta Câmara e do STJ. 3. Ademais, cumpre ressaltar que o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde. O tratamento postulado pela parte autora foi indicado pelo médico que a acompanha, não havendo que se falar em preenchimento das diretrizes de utilização do procedimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081651986, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2019) [Grifei]*
>
> *Apelação. Plano De Saúde. Negativa de cobertura para fornecimento do medicamento* ***Olaparibe (Lynparza)****. CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de outras provas - Incidência do art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER -* ***Medicamento autorizado pela ANVISA. Ainda que assim não fosse, os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está em tratamento e quando prescritos por médico.*** *Proteção do direito à vida (art 5º da CF). Inteligência do art. 35- F da Lei 9.656/98. Sentença mantida. Recurso improvido.(Apelação Cível, Nº 70079897203, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 28-03-2019) [Grifei]*

O compromisso firmado entre as partes pelo qual o dependente do médico cooperado tem a obrigação de pagamento do plano de saúde, ainda que em parte seja custeado pelos demais cooperados e que não incida a Lei 8.078/90, não isenta a aplicação da Lei 9.656/98, como expressamente previsto, cuja condição de dependente de cooperado não se encontra excepcionada.

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.

É relevante notar que, de acordo com a Lei n.º 9.656/98, o tratamento de que necessita o autor está dentre as coberturas mínimas a serem garantidas pelos planos de saúde, conforme se verifica abaixo:

> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;*
>
> *b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;*
>
> *b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;*
>
> *c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;*
>
> *d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;*

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e

f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos;

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar".

Nesse curso, não se pode olvidar que as normas contidas na Lei nº 9.656/98 possuem cariz eminente social e protetivo do consumidor (lato sendo), estando, inclusive, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Constitucional – notadamente para que não tenha protagonismo a assertiva de **Octávio Paz**: "O mercado sabe tudo sobre preços, nada sobre valores".

Há que dar lugar, em cumulação, ao princípio da função social do contrato, quanto ao qual o eminente Arnaldo Rizzardo[2] ensina que a par de impôr uma novel visão contratual

*"tem predominância a destinação social, nem sempre prevalecendo suas estipulações ou as cláusulas abusivas e que lesam valores superiores, como o da habitação ou moradia, o que trata da vida, **da saúde**, da formação, **do respeito, da dignidade**. (...)*

*(...)leva a prevalecer o interesse público sobre o privado, a impor o proveito coletivo em detrimento do meramente individual, a ter em conta mais **uma justiça distributiva que meramente retributiva**."*

Conforme supra mencionado, a tal princípio se agregam os princípios da probidade e da boa-fé inseridos no artigo 422 do Código Civil, sendo que sobre este último Maria Helena Diniz[3] comenta que

"É uma norma que requer o comportamento leal dos contratantes, sendo incompatível com quaisquer condutas abusivas, tendo por escopo gerar na relação obrigacional a confiança necessária e o equilíbrio das prestações e da distribuição dos riscos e encargos, ante a proibição do enriquecimento sem causa."

Outrossim, não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu artigo 1º, ao estabelecer os fundamentos do Estado Democrático de Direito impõe, dentre outros aspectos, a necessidade da observância da dignidade da pessoa humana, princípio este que, segundo leciona Alexandre de Moraes[4] se caracteriza

"(...) como um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos."

Já o artigo 3º, da Carta Constitucional, ao pontuar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, determina como tais a construção de uma **sociedade** livre, **justa e solidária** (inciso I), a **erradicação da pobreza** e a marginalização e **redução das desigualdades sociais** e regionais (inciso III), bem como a **promoção do bem de todos, sem preconceitos de** origem, razão, sexo, cor, **idade** e quaisquer outras formas de discriminação (inciso IV).

Nesse contexto, entendo que merece destaque, também, o fato de o artigo 6º, da Constituição Federal ter erigido a saúde à condição de direito social, o qual, saliente-se, é dispositivo de aplicação cogente e imediata, já que norma valorativa e representativa dos fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direito.

Diante de tais circunstâncias, fica evidente que a questão dos autos expõe um conflito de princípios travado entre os princípios originários da concepção clássica do contrato (liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos) e os novos princípios contratuais derivados do novel panorama principialista constitucional (função social do contrato, boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana, igualdade entre os cidadãos, dentre outros).

Nessa situação, outro caminho não vislumbro senão a preponderância dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da probidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade como forma de concretização dos preceitos e garantias constitucionais.

Sobre essa nova visão das relações jurídicas privadas, a qual implica necessariamente na constitucionalização do direito civil sob pena de manifesta incoerência do sistema jurídico pátrio, Cláudia Lima Marques[5] ensina que

"certos estão aqueles que consideram a Constituição Federal de 1988 como o centro irradiador e o marco da reconstrução de um direito privado brasileiro mais social e preocupado com os vulneráveis de nossa sociedade, um direito privado solidário".

Por tais motivos, reconheço a obrigação da demandada ao fornecimento do fármaco pleiteado, pelo prazo em que perdurar a necessidade do tratamento, não havendo escudo para sua negativa, a qual, por conseguinte, se apresenta abusiva/ não justificada.

Ao exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão formulada para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela deferida no E4 e determinar à UNIMED que forneça o fármaco "DUPIXENT (DUPILUMABE 300mg a cada 14 dias", conforme prescrição médica existente nos autos.

A requerida deverá ser intimada para, no prazo máximo de 48 horas, comprovar a disponibilização do medicamento ao autor, sob pena de bloqueio de valores.

Fica multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 200,00/dia, limitada a 30 dias.

Condeno a demandada ao pagamento da taxa única e despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, que fixo em 15% do valor da condenação de R$195.000,00 (correspondente ao valor anual de medicamentos), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, em atenção ao trabalho desenvolvido e à natureza da causa.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente, a contar desta data, bem como acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS DE MORAES PINTO, Juiz de Direito**, em 27/6/2023, às 19:45:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10034361861v49** e o código CRC **aff91464**.

---

1. Art. 4º da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS - RN Nº 555 (que revogou a Resolução 470): tem por finalidade assessorar a ANS na definição da amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, e de procedimentos de alta complexidade. ↩
2. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos, 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 21. ↩
3. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais, 20ª ed. Rev., aum. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10-01-2002) e o Projeto de Lei nº 6.960/2002. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 41. ↩
4. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 1998, p. 60. ↩
5. BENJAMIN, Antônio Herman V.. Manual de direito do consumidor. Cláudia Lima Marques, Leonardo Roscoe Bessa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2007, p. 27. ↩